

1501619-45.2021.8.26.0618  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: João Carlos Germano  
Comarca: Taubaté  
Foro: Foro de Taubaté  
Vara: 3ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 01/02/2022  
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
Raphael Marcondes Moreira

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Raphael Marcondes Moreira foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque por volta das 19h30min de 21 de novembro de 2021, na Rua José Vicente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Taubaté  
Foro de Taubaté  
3ª Vara Criminal  
Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal  
CEP: 12020-070 - Taubaté - SP  
Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501619-45.2021.8.26.0618 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1501619-45.2021.8.26.0618  
Classe - Assunto  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
Raphael Marcondes Moreira

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Raphael Marcondes Moreira foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque por volta das 19h30min de 21 de novembro de 2021, na Rua José Vicente de Barros, nº 440, Areão, Taubaté, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar, trazia consigo drogas para fins de tráfico.

Segundo apurado pela acusação, o réu solicitou transporte a um motorista de aplicativo. Durante o trajeto, ao perceber a aproximação policial, ele se abaixou no banco traseiro do veículo, o que despertou a atenção dos agentes públicos e motivou a abordagem.

Em revista pessoal, nada ilícito foi localizado com o motorista. No interior do veículo, no entanto, foram apreendidos 66 pinos de cocaína (peso líquido de 38,55 gramas) escondidos embaixo do banco em frente ao assento que o réu ocupava. Segundo os policiais, quando indagado, o réu teria confessado informalmente a prática do tráfico de drogas, alegando que estava devendo para traficantes e que cada transporte de drogas abateria R\$ 100,00 de seu débito.

A denúncia foi recebida às fls. 48/50.

Citado (fls. 75), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 122/128).

Designou-se audiência em que foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Argumentou que há provas suficientes da materialidade e da autoria, especialmente pela prova testemunhal colhida em juízo. Destacou a quantidade das drogas apreendidas. Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Pugnou pelo agravamento da pena em razão da reincidência. Rechaçou a possibilidade de concessão do redutor previsto na Lei de Drogas. Pediu a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa pediu a absolvição do réu. Argumentou que a narrativa dos policiais não resultou comprovada nos autos. Aduziu que a fragilidade de provas impõe a absolvição. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal. Pugnou pela aplicação do redutor previsto na Lei 11.343/06. Requereu a imposição de regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu ao réu a autoria de tráfico de drogas, dando-o como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade e a autoria delitivas encontram arrimo em auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/5), termo de depoimento (fls. 6/8), interrogatório (fls. 9), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de qualificação (fls. 22), laudo pericial (fls. 118/121) e depoimentos colhidos em juízo.

Ouvida em juízo, a testemunha João Claudio Ferreira disse que estava em patrulhamento com a equipe BAEP quando avistou o réu e outro indivíduo no interior de um veículo Agile, cor prata. Contou que o réu se abaixou no banco do passageiro ao perceber a presença da polícia, o que motivou a abordagem. Asseverou que, ao ser abordado, o réu indicou que havia escondido algumas porções de droga embaixo do banco frontal de passageiro. Afirmou que o réu também carregava dinheiro. Segundo informado pelo réu, ele receberia dinheiro em troca do transporte das drogas, pois estava com dívidas com o tráfico. Não conhecia o réu.

André de Souza Pinto disse que estava em patrulhamento quando viu o réu tentando se esconder no interior de um carro que passava pelos policiais. Submetido à abordagem, o réu foi flagrado na posse de cocaína e outras drogas. Questionado, o réu falou que era usuário de drogas e estava indo buscar outras drogas. Posteriormente, ao perceber que o veículo seria alvo de buscas, o acusado confessou

que havia escondido algumas porções de drogas no banco do veículo. Segundo informado pelo acusado, ele estava com dívidas com traficantes e os transportes de drogas abateriam seu débito. Aduziu que o réu informou que aquela era sua terceira viagem no dia.

A testemunha Wesley Felipe Araújo informou que trabalhava como motorista de aplicativo de transporte de passageiros. Relatou que foi chamado para atender uma pessoa com nome Ricardo, mas descobriu posteriormente que o passageiro tinha outro nome. Aduziu que o passageiro saiu de uma casa e comentou que estava a caminho da casa de uma mulher. Asseverou que, ao passar por determinada rua, a polícia apontou seu farol para o interior do veículo. Em seguida, viu a viatura andando na sua frente e novamente viu um farol em direção ao carro. Pontuou que os policiais indagaram se o passageiro possuía tatuagens e se havia sido preso. Contou que foi abordado separadamente do réu e permitiu que revistassem seu veículo. Respondeu às perguntas dos policiais. Ouviu os policiais perguntando ao réu: "é só isso aqui?". Posteriormente, viu os policiais retirarem algum pacote do interior do carro. Afirmou que todos foram conduzidos à delegacia. Não ouviu outros detalhes sobre o fato.

Interrogado, o réu negou a autoria dos fatos. Disse que estava na casa de Ricardo e carregava consigo R\$ 60,00 e um pino de cocaína. Aduziu que estava indo à casa de sua amiga Ana Carolina. Negou que tenha se abaixado no interior do carro. Confessou aos policiais que tinha uma única porção de cocaína consigo. Afirmou que os policiais revistaram o carro e apresentaram algumas porções de drogas, dizendo que lhe pertenciam. Não conhecia os policiais nem o motorista do veículo. Afirmou que já respondeu a processo criminal por tráfico de drogas. Aduziu que é usuário de cocaína há aproximadamente oito anos e, inclusive, já permaneceu internado. Disse que sempre trabalhou. Havia comprado a porção de cocaína em uma "biqueira" próxima à casa de seus pais.

Bem provadas a autoria e a materialidade do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Observe-se que a conduta do réu se enquadra em ao menos um dos verbos-núcleo do tipo, notadamente trazer consigo drogas para fins de tráfico, resultando configurada a tipificação do crime em destaque.

A própria prisão em flagrante comprova que o réu transportava 66 microtubos contendo, no total, 38,55 gramas de cocaína, droga que seria destinada ao comércio direto a usuários (fls. 11 e 15/17).

Em adição à prisão em flagrante, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais foram coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo com fidelidade o quanto afirmado durante a fase do inquérito, dando conta do ocorrido na data dos fatos. Ambos desceram a minúcias, retratando o fato como realmente passado, dizendo como se deu a prisão e as demais circunstâncias em que foram encontradas as drogas com o réu.

Informaram os milicianos que estavam em patrulha rotineira quando perceberam que o réu, que estava no interior de um veículo, se abaixou no banco de trás para tentar se esconder. Contaram que decidiram abordar os ocupantes do veículo e descobriram que se tratava de um motorista do aplicativo Uber transportando o réu como passageiro. Disseram que o motorista não carregava nada de ilícito consigo, mas

localizaram as porções de cocaína embaixo do banco em frente ao local ocupado pelo réu. Asseveraram que o réu confessou que estava transportando drogas em troca de dinheiro, pois estava devendo para traficantes.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Somada à palavra dos policiais militares, a narrativa do motorista do veículo também demonstra a ilicitude da conduta do acusado. Interrogado em juízo, a testemunha disse que autorizou os policiais a revistarem seu veículo e os viu retirarem um pacote do interior do carro. Pontuou que os milicianos perguntaram ao passageiro se ele carregava algo mais de ilícito consigo.

Inadmissível a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o réu não cumpre os requisitos previstos, especialmente por ser reincidente (fls. 23/27).

De se anotar que a redução prevista na lei busca alcançar e tem por finalidade aquele pequeno traficante, o traficante fortuito. É a ele que a lei visa a conceder a benesse, promovendo-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive.

Tinha o réu pleno conhecimento da ilicitude do fato e, mesmo assim, decidiu determinar-se nesse caminho.

A prova é certa, segura e dá conta do cometimento do crime pelo réu, que deve responder pelo ilícito praticado.

Estabelecida a responsabilidade do réu, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente à individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59, da Lei Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A natureza da droga e sua quantidade não pesam em desfavor do réu, porquanto se trata de quantidade não excessiva que não justifica o aumento da pena base. Anote-se que, em peso líquido, foram apreendidos aproximadamente 38,55 gramas de cocaína (fls. 11 e 15/17).

O réu ostenta registros criminais, que deixo para valorar na segunda fase da dosimetria, por configurar reincidência.

A personalidade do agente – que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que, em razão de seu proceder, pode proferir decisão equivocada e injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

Ainda que não majoritário na jurisprudência, o entendimento acima explicitado tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017:

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo "A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"([http://www.esmp.sp.gov.br/revista\\_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68](http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68)).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" (A mentira do réu e a Dosimetria da Pena; artigo de autoria do Promotor de Justiça Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado e disponível endereço eletrônico <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Cabe anotar, em remate, que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamentos recentes, por votação unânime, vem decidindo no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sales Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo "fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime" (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3ª Vara Criminal, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372 (1ª Vara Judicial de Hortolândia, Juiz de Direito Luís Mário Mori Domingues j. 21.01.2015):

"(...) escoreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, "nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu,

silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo", demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida" (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625; 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Ivana David, j. em 10.12.2019)

Os motivos do crime são os naturais à espécie, bem como as consequências e as circunstâncias são ordinárias, sendo neutras para o fim de fixação da pena. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico 'saúde pública', não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, partindo da pena mínima em abstrato, acresço-a de 1/6 e fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, impende reconhecer a reincidência do réu, conforme se extrai das certidões de fls. 23/27 (processo n. 0000048-89.2016.8.26.0618). Por outro lado, não concorre qualquer circunstância atenuante, razão pela qual aumento a pena em 1/6, que passa a totalizar 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa.

Na terceira fase, não se afere causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o fechado, em razão da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'a', e §3º, do Código Penal.

Ademais, trata-se de condenação por tráfico de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta, que pode ser verificada pela expressiva quantidade de porções individuais, bem como pelo potencial de difusão do vício da droga apreendida, também exige maior rigor por parte do Estado.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, porque o réu não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, especialmente pela quantidade de pena imposta e pela reincidência. Igualmente inviável a suspensão condicional da pena, porquanto não preenche o réu os requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Mantenho a prisão, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres



Britto, DJe 28/8/2008; STF, HC n. 114536/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/10/2013).

No caso o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo réu é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do réu (artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Mantida a custódia cautelar nos termos acima explicitados, dá-se cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Registre-se que a vítima é a sociedade.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos com o réu em favor da União Federal, pois não foi comprovada a origem lícita do dinheiro encontrado na posse dele.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Raphael Marcondes Moreira à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 1º de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA